

1512503-95.2021.8.26.0566

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EDUARDO CEBRIAN ARAUJO REIS

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado, regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório. DECIDO.

Preliminarmente, afasto a arguição aventada nas alegações finais defensivas, haja vista que, tratando-se o tráfico de entorpecentes de delito permanente, não há irregularidade na deflagração da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

3ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, São Carlos-SP - cep 13560-140

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512503-95.2021.8.26.0566 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512503-95.2021.8.26.0566

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2325610/2021 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 21690965 -

DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 2325610 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

FABIANI DOS SANTOS KAPP

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EDUARDO CEBRIAN ARAUJO REIS

Vistos.

FABIANI DOS SANTOS KAPP, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 30 de novembro de 2021, por volta das 15h, na Rua Martin Luther King, 1500, Vila Boa Vista, nesta cidade e comarca de São Carlos/SP, trazia consigo, para fins de venda e comercialização, 42 (quarenta e duas) pedras de crack, com peso líquido de 4.12g (quatro gramas e cento e vinte miligramas), drogas acondicionadas de forma a pronta entrega a consumo de terceiros, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 22, foto de fls. 23, laudo de constatação de fls. 25/27 e laudo químico de fls. 51/53, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A ré foi presa em flagrante, sendo-lhe concedida liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares (fls. 39/41).

Notificada, a ré apresentou defesa prévia à fl. 75.

A denúncia foi recebida em 02 de junho de 2022 (fl. 76).

Designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, realizada por videoconferência. Na solenidade, procedeu-se à oitiva de três testemunhas e decretou-se a revelia da acusada (fl. 96).

Realizados os debates orais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, com aumento da pena-base pela quantidade de drogas e afastamento do tráfico privilegiado.

A Defensoria Pública, de outra parte, arguiu ilegalidade na conduta dos guardas municipais, que não teriam legitimidade para proceder à busca pessoal. No mérito, pediu a desclassificação para o crime de uso de drogas. Subsidiariamente, requereu fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado, regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório. DECIDO.

Preliminarmente, afasto a arguição aventada nas alegações finais defensivas, haja vista que, tratando-se o tráfico de entorpecentes de delito permanente, não há irregularidade na deflagração da prisão em flagrante ainda que levada a efeito por guardas municipais.

Verte do acervo probatório que os agentes públicos agiram em situação de flagrância, o que, por comando legal, autoriza qualquer do povo a agir (artigo 301, CPP).

Não se observou, na hipótese, função investigativa, cumprindo a atuação o disposto no art. 144, § 8º, da CF.

Nesse sentido: “Destaca-se que o contexto acima apresentado se amolda ao posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, eis que a Corte Superior decidiu que “havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa” (STJ - AgRg no HC n. 667.413/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 16/6/2021), portanto, descabe cogitar de inobservância do artigo 144, § 8º da Constituição Federal e dos artigos 4º e 5º da Lei 13.022/14, mesmo porque o artigo 3º, inciso III da referida lei prevê, dentre os princípios que norteiam a atuação da guarda municipal, o patrulhamento preventivo. Cumpre consignar que “os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal” (STJ AgRg no HC n. 595.816/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022), ou seja, não há que se falar em prova ilícita a ser desentranhada, a teor do artigo 5º, inciso LVI da Constituição Federal.” (TJSP; Apelação Criminal 1505279-60.2020.8.26.0625; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taubaté - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/10/2022; Data de Registro: 19/10/2022).

E ainda: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A permissão para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo. 2. Uma vez que havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, são lícitas todas as provas obtidas por meio dessa medida. 3. É possível que, durante o patrulhamento preventivo, destinado à salvaguarda da população local, bem como de bens, serviços e instalações, as guardas municipais se deparem com situação de flagrante delito ou, ainda, que, diante de notícia criminis, envolvendo qualquer dos bens jurídicos mencionados, procedam à atividade de vigilância no local indicado para se certificar de sua veracidade, hipóteses nas

quais, de nenhum modo, estariam desautorizadas a agir. 4. A situação de flagrância delitiva legitima a atuação de "qualquer pessoa do povo" a proceder à prisão, oportunidade em que é perfeitamente possível a realização da abordagem do suspeito, não sendo diferente em relação àqueles agentes que, ao realizarem seu mister de zelar pelo patrimônio público, muitas vezes se deparam com infrações penais, sendo-lhes lícito atuar em tais ocasiões. 5. O Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgados, já manifestou entendimento de que o art. 144 da Constituição Federal não estabelece o monopólio da função de investigação criminal à polícia. Destarte, a sua interpretação, vista em conjunto com o art. 4º, parágrafo único, do Código de Processo Penal, legitima a atuação investigativa por outras autoridades. 6. Uma vez que os depoimentos prestados pelo acusado não foram utilizados para a formação do convencimento do julgador – que se valeu dos demais elementos fático-probatórios colacionados aos autos para concluir pela condenação no tocante à prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 –, e porque não houve o reconhecimento da traficância pelo réu (Súmula n. 630 do STJ), não há como se lhe aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP. 7. Porque o réu, além de haver sido condenado a reprimenda superior a 4 anos de reclusão, era reincidente (inclusive específico) ao tempo do crime, mostra-se devida a imposição do regime inicial fechado de cumprimento de pena. 8. Agravo regimental não provido." (STJ - AgRg no HC n. 621.586/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/09/2021, DJe de 29/09/2021).

A ação penal é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fl. 22, pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 51/53, bem como pela prova oral produzida.

A autoria também é certa.

A ré não compareceu à solenidade, sendo decretada sua revelia.

Ouvidos em juízo, os agentes públicos prestaram declarações essencialmente harmônicas.

O guarda municipal Hilton Aparecido Francisco declarou que na data dos fatos visualizou duas pessoas que aparentemente estariam usando ou comercializando entorpecentes. Informou que no local há incidência de venda e consumo de drogas. Disse que nenhum dos abordados aparentava estar sob efeito de entorpecentes. Realizada a revista pessoal, com o indivíduo do sexo masculino nada foi localizado. A acusada, por sua vez, trazia consigo, em um compartimento de suas vestes, 42 pedras de crack. Além disso, houve a apreensão de pequena quantia em dinheiro. Luiz Aparecido de Medeiros, também guarda municipal, disse que estava em patrulhamento quando avistou algumas pessoas que aparentemente faziam o uso de entorpecentes. Durante a abordagem a ré demonstrou nervosismo. Mencionou que o rapaz jogou o que parecia ser uma ponta de cigarro de maconha no chão e pisou em cima, deteriorando-a. Realizada a busca pessoal na acusada, foram localizadas as drogas descritas na denúncia.

A guarda municipal Karine de Fátima Fellipe relatou que foi chamada a realizar a busca pessoal em uma mulher abordada por outros agentes. Disse que a droga localizada com a acusada estava bem escondida em suas vestes. Acrescentou que o local é conhecido ponto de tráfico de entorpecentes.

As circunstâncias da abordagem, a quantidade de entorpecentes, a apreensão de numerário, o local do fato, apontado como local de tráfico de drogas, indicam que na oportunidade a acusada promovia o comércio clandestino.

Não há dúvidas acerca da prática da conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, inviabilizando-se a pretendida desclassificação.

Nesse aspecto, a prova oral é suficiente para comprovar os fatos, inexistindo motivo para levantar suspeição sobre a palavra das testemunhas, as quais não teriam motivo para lançar assaques gratuitos contra a ré.

Neste contexto, observo que a quantidade de entorpecente apreendido afasta alegação de mero uso. Não é crível que 42 pedras de crack destinavam-se ao consumo próprio da acusada, sobretudo porque foi abordada na rua, em local de alta incidência de comércio espúrio, trazendo consigo as porções, todas individualizadas, escondidas em sua vestimenta.

Além disso, para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias. O delito se consuma quando o agente traz consigo o entorpecente para entrega e consumo de terceiros.

Ressalte-se que não foram localizados em poder da ré artefatos que indicassem a utilização dos tóxicos, tampouco a prova oral indicou tal circunstância. Inviável, portanto, a pretendida desclassificação.

De rigor, em consequência, o acolhimento da pretensão condenatória expressa na denúncia.

De outra parte, a ré é primária e não há comprovação de que integre organização criminosa ou que faça da atividade ilícita seu meio de vida, devendo ser reconhecida em seu favor a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. O redutor deve ser o do patamar máximo, pois as circunstâncias judiciais são favoráveis à agente.

Passo a dosar a pena.

Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Por força da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, já reconhecida, reduzo a reprimenda em 2/3 (dois terços), totalizando 01 ano, 08 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Estabeleço regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta (artigo 33, parágrafo 2º, "c", do Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno a ré FABIANI DOS SANTOS KAPP como incurso no artigo 33, caput e §4º, da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo.

Não obstante a gravidade em concreto da infração, diante da primariedade da agente, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em: (a) uma de prestação de serviços à comunidade, na razão de uma hora por dia de condenação; (b) uma de multa, no valor de 10 (dez) dias-multa, na forma especificada

Declaro o perdimento de bens e valores apreendidos, pois decorrentes da prática da infração penal ou utilizados no cometimento do ilícito.

Autorizo a incineração das drogas.

Considerando que a ré permaneceu solta durante o curso do processo e tendo em vista a substituição da pena, autoriza-se recurso em liberdade.

Não há custas nessa fase, por ser a ré beneficiária da justiça gratuita.

P.I. Oportunamente, arquivem-se.

São Carlos, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA